

1528084-97.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ALBERTO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

RAFAEL ALBERTO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528084-97.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528084-97.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ALBERTO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

RAFAEL ALBERTO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo

processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 11h00min, durante estado de calamidade pública (Decreto Estadual nº 64.879/2020 - COVID-19), na Avenida do Estado, nº 3.445, Sé, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros

(I) 112 (cento e doze) porções de cocaína, pesando 26,3 g (vinte e seis gramas e três decigramas);

e (II) 14 (quatorze) porções de tetrahydrocannabinol, substância conhecida como maconha, pesando 39,1 g (trinta e nove gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R\$ 37,00 (trinta e sete reais) em espécie.

O acusado, notificado nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, apresentou Defesa Prévia, subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos (págs. 99/100).

Recebida a denúncia (págs. 101/103), designou-se audiência concentrada de instrução e julgamento, o acusado foi citado e interrogado ao final, e na mesma oportunidade foram ouvidas as testemunhas arroladas.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos termos da denúncia, ao passo que a Douta Defesa requereu a absolvição e sustentou, em síntese, precariedade probatória. Alternativamente, pugnou pela aplicação do redutor de pena previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena; direito de interpor recurso em liberdade; e, por fim, desclassificação do crime denunciado para a figura típica prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 05 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 33/36); auto de exibição e apreensão (pág. 22); imagem das substâncias e da quantia em dinheiro apreendidas (pág. 24); laudo de constatação (págs. 29/32); laudo pericial de exame químico-toxicológico (págs. 123/125), que resultou positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol nas substâncias analisadas, bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado confessou a prática do delito, afirmando: " (...) que, 'in loco', comercializava a venda de drogas, disse que, devido a prisão de outrem (pessoa que praticava a mesma conduta e foi presa) e como a 'vaga' estava aberta, dois indivíduos (desconhecidos) o convidaram para vender as drogas e como pagamento, inicialmente, deram-lhe 4 (quatro) pedras de crack e ao final lhe dariam R\$ 50,00 (cinquenta reais). Demais disso, o indigitado disse que 'não se ligou' e foi surpreendido pelos Policiais Militares. Neste momento, tentou 'dispensar' o dinheiro e os dois invólucros contendo o total de 28 (vinte e oito) pedrinhas (14+14), no entanto os Policiais Militares apreenderam, assim como o restante que deixou sob uma mesa que a improvisou para vender as drogas (...) " (pág. 13).

No contraditório, apresentou outra versão aos fatos.

Narrou que é usuário e viciado no consumo de drogas.

Dirigiu-se ao local dos fatos para adquirir entorpecente para consumo, e portava a quantia de R\$37,00, oriunda de seu trabalho como técnico em manutenção.

Disse que é proprietário de uma oficina localizada em sua residência, e à época estava trabalhando em uma obra.

No dia do ocorrido, esteve no local onde foi abordado por policiais, ponto de venda de drogas, pediu ao traficante uma porção de maconha e uma de crack "...pra mim misturar...". O rádio do traficante tocou, ele se afastou e entrou em uma residência.

Ressaltou que por não saber o que estava ocorrendo, permaneceu no local, e foi surpreendido pelos policiais militares.

Acrescentou que ainda não havia recebido a droga do traficante, e os policiais localizaram porções de entorpecentes em cima de uma mesa. Esclareceu que o local é uma invasão, atravessou um corredor e logo que chegou viu que o traficante estava com as drogas em cima de uma mesa. Havia uma lixeira embaixo.

O traficante saiu depois de ter recebido uma mensagem pelo rádio comunicador, e foi surpreendido e abordado pelos policiais militares. Na oportunidade, as drogas não estavam em seu poder, e negou ter confessado a responsabilidade pela mercancia. A confissão extrajudicial se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório, sobretudo diante da localização de entorpecentes fracionados e diversificados em poder do acusado, em notório ponto de venda de drogas.

Ao contrário, a singela negativa de autoria que apresentou em juízo restou isolada nos autos, desacompanhada de demonstração probatória de veracidade, sendo infimada pelos robustos elementos probatórios produzidos, que comprometeram sobremaneira o acusado.

Os policiais inquiridos, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, já sob o crivo do contraditório, apresentaram esclarecimentos convergentes a respeito dos fatos, narrando de forma insuspeita como se desenrolou a diligência que realizaram, ensejada que foi pelo comportamento suspeito do acusado.

Narraram que patrulhavam pelo local, notório ponto de venda de drogas, e viram que o acusado estava sentado, mostrando-se assustado quando notou que se aproximavam. Nesse momento ele se levantou rapidamente, e dispensou algo ao solo. O acusado tentou fugir, mas não teve tempo; o abordaram e constataram que ele havia dispensado algumas pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

Havia uma lixeira ao lado do acusado, e no interior dela encontraram várias outras porções da mesma droga, e também de maconha, e mais uma quantia em dinheiro.

Na oportunidade, o acusado admitiu que promovia a mercancia no local, que estava cansado, uma vez que havia assumido o ponto de venda de drogas às 23h da noite anterior, e o traficante que teria que substituí-lo pela manhã não havia comparecido.

Diante de tais circunstâncias, proferiram voz de prisão em flagrante ao réu, que mais tarde foi ratificada pela Autoridade Policial.

Como consignado, o conjunto probatório produzido bem demonstrou a responsabilidade do acusado pelo crime que lhe foi imputado na denúncia.

Com efeito, apresentou esclarecimentos totalmente contraditórios nas oportunidades em que foi interrogado.

Na fase policial, ainda no calor dos fatos, admitiu amplamente o cometimento do crime.

No contraditório, entretanto, se retratou e negou qualquer responsabilidade pelo crime, afirmando que pretendia comprar drogas para consumo, o que não havia feito ainda.

Entretanto, não produziu uma única prova da inconsistente negativa de autoria que apresentou em juízo.

Ao contrário, a detalhada confissão prestada em solo policial se ajustou aos elementos de convicção produzidos em juízo, calcados nos esclarecimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a diligência.

No caso em apreço, o réu foi surpreendido enquanto trazia considerável quantidade de drogas, fracionadas em pequenas porções, prontas para o comércio, não apresentando justificativa convincente quando instado, restando evidente que estava no local realizando o comércio espúrio.

No mais, os policiais inquiridos, de forma serena, deram conta da diligência que realizaram, já que patrulhavam pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, surpreenderam o acusado, que mostrou-se assustado, jogou um pacote no chão, tentou se afastar, de forma que o abordaram e localizaram as drogas que ele havia dispensado, bem como outras em uma lixeira.

E os esclarecimentos apresentados pelos policiais, é sempre bom consignar, são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade, e a

versão que apresentaram só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas".(TJRJ - AC - Rel Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

De resto, o destino do tóxico apreendido é manifesto.

O réu portava expressiva quantidade de crack e maconha, drogas separadas em porções individuais.

O local - ponto de tráfico -, as circunstâncias da prisão, e a forma como os entorpecentes estavam acondicionados, afastam qualquer dúvida quanto à sua finalidade, de forma que não há que se falar em desclassificação do crime denunciado para o previsto no artigo 28 da Lei especial. Ademais, o acusado não admitiu a posse do tóxico apreendido para consumo.

Assim não fosse, a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que "Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (TJSP - AC 9.751-3 - Rel. Gonçalves Sobrinho - RJTJSP 75/343).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76." (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

Demonstrada a ocorrência do delito, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Os documentos juntados aos autos (F.A. e certidão - págs. 72/77 e 79/80, respectivamente) são comprobatórios de reincidência.

Logo, pelos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Incidu, no caso concreto, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cumprе salientar que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente. Para o reconhecimento da agravante em questão - temporal objetiva -, basta que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral do agente e ausência de fraternidade e solidariedade social. Ademais, o acusado praticou crime que compromete a saúde pública, já profundamente abalada pela pandemia.

Todavia, referida agravante fica compensada com a atenuante da confissão espontânea, já que na fase policial o acusado admitiu o cometimento do crime. São três as condenações definitivas que configuram reincidência, oriundas de processos que tramitaram perante a 2ª e 5ª Varas Criminais da comarca de Ribeirão Preto, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/04/17, 22/04/19 e 25/01/16, respectivamente).

Desta forma, pela tripla reincidência, agravo a pena na fração de 1/3, tornando-a definitiva em seis anos e oito meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal.

Em se tratando de réu reincidente, não estão presentes os requisitos do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06.

E não existe a desproporção no que diz respeito a dosimetria da pena, por conta da

reincidência.

Ainda, a lei não exige que a reincidência seja configurada por crime da mesma natureza, como forma de impedir a aplicação do redutor de pena em questão.

Nesse sentido: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.

TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POSSE OU PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. REINCIDÊNCIA VALORADA COMO

CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL

FECHADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.

- Na hipótese sub exame, configurada a reincidência, posto persistente a tipificação do delito de posse para uso próprio, bem como não existe a necessidade que a condenação definitiva pelo delito anterior seja privativa de liberdade. Precedentes.

- Possível a considerar a reincidência como circunstância agravante na segunda fase de dosimetria da pena, bem como para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem que se configure bis in idem, pois tal instituto possui finalidade jurídico-legal distinta em cada etapa de aplicação da pena, conforme expressa previsão legal.

- O Supremo Tribunal Federal, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.

- No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e diversidade das drogas apreendidas - 26 porções de crack e 1 (um) invólucro plástico de cocaína, (sabe-se que o crack é uma substância que possui um alto efeito devastador, devendo-se impor um maior rigor na apreciação da conduta do paciente) - , e a reincidência da paciente, justificam a imposição do regime inicial fechado, bem como a não substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido.". (HC 236982 SP 2012/0058827-2 Relatora: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE)).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra RAFAEL ALBERTO DE OLIVEIRA, R.G. nº 42.741.612-7, e o condeno ao cumprimento de seis anos e oito meses de reclusão e ao pagamento do valor seiscentos e sessenta e seis dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, tendo em vista o que dispõe a Lei 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, §1º da lei 8.072/90.

Pela gravidade do crime, considerado hediondo, e pela comprovada reincidência, para garantia da ordem pública e para assegurar o cumprimento da pena aqui aplicada, o acusado não poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra, e igualmente não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais.

Pelos mesmos argumentos, mantenho a prisão preventiva decretada, uma vez que persistem as razões que motivaram a medida, reforçadas que foram pelos elementos de

convicção produzidos nos autos (artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal).

Nos termos dos artigos 62 e seguintes da Lei 11.343/06 e do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, DETERMINO a perda em favor da União da quantia em espécie apreendida R\$ 37,00 (trinta e sete reais), relacionada no auto de exibição e apreensão (pág. 22), uma vez que oriunda da venda de drogas.

Condene o acusado ao pagamento das custas do processo, nos termos do que estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA